

1501411-85.2021.8.26.0222

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501411-85.2021.8.26.0222 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501411-85.2021.8.26.0222

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238751/2021 - DEL.POL.GUARIBA, 19996077 -

DEL.POL.GUARIBA, 2238751 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ASSUNCAO HONORIO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou GABRIEL ASSUNÇÃO HONORIO E ANTONIO NONATO DE ARAUJO DO NASCIMENTO como incursos nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, e Antonio também como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826/03, porque no dia 01 de setembro de 2021, às 09h15min, na Avenida Elias Gazone, n. 190, Bairro Vila Amorim, nesta cidade e comarca de Guariba, guardavam, traziam consigo e tinham em depósito, para entrega e consumo de terceiros, 12 eppendorfs contendo cocaína, 04 porções de maconha e 01 porção de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Avenida Francisco Vitorine, n. 80, Bairro Alto, nesta cidade e comarca, o denunciado ANTONIO NONATO DE ARAUJO DO NASCIMENTO possuía e matinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma munição de arma de fogo de uso

permitido, qual seja, munição de calibre 38, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia às fls. 216/217 e 222/229.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo os réus interrogados ao final.

As partes apresentaram memoriais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação dos réus. Na dosimetria, pediu a majoração da pena base acima do mínimo legal, considerando a quantidade e espécie de drogas apreendidas; na terceira fase pediu que seja afastada a causa de diminuição de pena – por serem os réus conhecidos dos meios policiais e variedade de entorpecentes, a denotar envolvimento com a criminalidade. Ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, postulou regime inicial fechado.

Pela defesa de Gabriel, postulou o reconhecimento das atenuantes da confissão e da maioridade relativa, bem como o reconhecimento da causa de diminuição da pena pela pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, alegando ainda a ausência de maus antecedentes.

É o sucinto RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 14/24), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 35/36), pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 130/139), bem como pela prova oral colhida em audiência de instrução, debates e julgamento.

O policial Dieimes, ouvido em Juízo, disse que receberam denúncia no dia dos fatos de que dois indivíduos estariam efetuando a traficância em um bar. Chegando ao local surpreenderam os acusados, vulgo Gigante e vulgo Maranhense. Afirmou que ao perceberem a presença policial tentaram passar uma sacola preta de um para o outro. Abordados, foi constatado que dentro da sacola estavam os entorpecentes. Disse que na casa de Antonio foi encontrada a munição de uma arma.

O policial Antonio, ouvido em Juízo, disse que no dia dos fatos recebeu denúncia de que dois indivíduos estariam realizando a venda de drogas. Chegando ao local, visualizou um dos réus passando uma sacolinha para o outro quando viram a viatura. Efetuaram a abordagem e encontraram uma pochete com o acusado conhecido como Maranhense. Disse que na residência de Maranhense foi localizada uma munição de revólver.

O acusado Gabriel, ouvido em Juízo, afirmou que estava no local para comprar drogas para o uso pessoal. Disse que não tem nada a ver com Antônio e que não o conhecia. Afirmou que parte do que iria comprar era para revender.

O acusado Antonio, por sua vez, negou os fatos. Disse que não estava com o corrêu e que tinha apenas um entorpecente em seu bolso. Afirmou que não havia vendido nenhuma droga para o corrêu. Em relação à munição, afirmou que estava há 15 dias com ela e que já iria dispensar.

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

Ora, não se trata simplesmente de desmerecer as versões dos acusados.

É que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

O simples fato de estas testemunhas pertencerem aos quadros da polícia e terem participado das diligências que culminaram com a prisão do acusado não os torna indignos de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios investigadores ou policiais militares que cuidaram do caso nas fases extrajudiciais, já que não existe qualquer impedimento nesta dupla atuação. Ora, a partir do momento em que o Estado legitimou a investidura da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade, pode e deve o Estado-juiz conceder-lhes o mesmo

crédito inicialmente depositado quando narram suas atividades, já que cientes de seu compromisso de dizer a verdade, sujeitos às penas do crime de falso testemunho ou de denúncia caluniosa, exatamente como os demais cidadãos. Neste sentido: "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação" (TJSP, Apelação Criminal nº. 128.275-3/9 - Rel. Des. Canguçu de Almeida)"

Quanto à afirmação de que é mero usuário, a forma com que as drogas foram apreendidas não se coaduna com a situação de quem pretendia consumi-las para saciar seu vício.

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4ª Câmara de Direito Criminal Apelação nº 0000248-23.2016.8.26.0610 - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que o recorrente não comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram evidenciados os atos de traficância pela quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack' e um pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal condição não afasta a qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo de tráfico." (Apelação Criminal Nº 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005)"

De outra parte, ainda que os policiais não tenham presenciado os réus em atitude típica de traficância, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. Isso porque a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, pelas circunstâncias, está claro o propósito de tráfico, tanto pela quantidade quanto pela forma de acondicionamento dos entorpecentes.

Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que os acusados traziam consigo quantidade de substância entorpecente, eles devem ser responsabilizados pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Quanto ao acusado Antônio, em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, é de se pontuar que os crimes de posse de arma de fogo são de perigo abstrato, em que é desnecessária prova de que a conduta provocou dano ou submeteu ou poderia submeter alguém a perigo direto (AgRg no REsp 1.692.637/SC).

Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

GABRIEL ASSUNÇÃO HONÓRIO

Na primeira fase, ante inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa e da confissão. Todavia, deixo de aplicá-la em observância à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento da pena.

Os requisitos (cumulativos) para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser a agente

primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado. Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretarem à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levada em conta a quantidade substâncias apreendidas. Parece-me razoável asseverar que quanto maior a quantidade, mais variados os tipos e o campo de comercialização deles, menor a diminuição da pena. É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 – Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09). Nesta esteira, atento a natureza e quantidade dos entorpecentes, é que a redução deverá ser feita na proporção de 1/4 (um quarto), perfazendo o total de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 1.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Desta forma, ainda em razão da natureza da droga, bem como das circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante o art. 33, § 2º, do Código Penal.

Altero meu posicionamento anterior a fim de conceder ao réu, ante o teor da pena aplicada, primariedade e demais requisitos objetivos, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo tempo de condenação e (2) entrega de bens a entidades do juízo no importe de 1 salário mínimo, como de praxe nesta comarca.

Maiores detalhes sobre a forma de cumprimento destas penas alternativas serão apontados pelo juízo das execuções.

Sem detração ou progressão neste ato, tanto porque ainda não cumpridos o requisito objetivo (temporal), quanto pelo fato de que ausentes elementos para análise do requisito subjetivo, devendo tal matéria ser analisada pelo juízo competente, ou seja, o das execuções – aliás, como vem entendendo a jurisprudência do E. TJ/SP.

ANTONIO NONATO DE ARAUJO DO NASCIMENTO

Art. 33 da Lei 11/343/06:

Na primeira fase do sistema trifásico, considerando as circunstâncias judiciais, conforme dispõe o artigo 42, da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59, do Código Penal, verifico que a fixação da pena-base deve ser no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo o montante de 05 (cinco) anos e reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento da pena.

Os requisitos (cumulativos) para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser a agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado. Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o

interpretarem à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levada em conta a quantidade substâncias apreendidas. Parece-me razoável asseverar que quanto maior a quantidade, mais variados os tipos e o campo de comercialização deles, menor a diminuição da pena. É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 – Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09). Nesta esteira, atento a natureza e quantidade dos entorpecentes, é que a redução deverá ser feita na proporção de 1/4 (um quarto), perfazendo o total de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

- Art. 12 da Lei 10.826/03

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 01 ano de detenção e pagamento de 10 dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem computadas;

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno, pois, definitivo o quantum da pena em um ano de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, chega-se ao montante de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, além de 01 (ano) de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa.

No presente caso, em decorrência da quantidade da pena aplicada, não há outro regime inicial a ser aplicado que não o semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e:

A) CONDENO GABRIEL ASSUNÇÃO HONORIO como incurso no artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual substituo por duas restritivas de direito, consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo tempo de condenação e (2) entrega de bens a entidades do juízo no importe de 1 salário mínimo, como de praxe nesta comarca.

B) CONDENO ANTONIO NONATO DE ARAUJO DO NASCIMENTO como incurso no artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, além da pena de 01 (ano) de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Expeça-se alvará de soltura em relação ao condenado Gabriel.

Não obstante, não concedo o apelo em liberdade para o condenado Antonio, uma vez que presentes as razões que determinaram a preventiva.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que é beneficiário da gratuidade de justiça (advogado nomeado em razão do convênio entre a OAB/SP e a DPE/SP). Expeça-se certidão de honorários, nos termos máximos previstos na tabela de regência.

P.I.C.

Guariba, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA